

AUTO NUMERO: 418

Córdoba, 26 de noviembre de dos mil catorce.--

Y VISTOS: Estos autos caratulados: **“REPARTIDORES DE KEROSENE DE YPF DE CBA SRL HOY MUÑOZ LUIS ALBERTO C/ FRUTACOR S.A. – ORDINARIO – CUMPLIMIENTO / RESOLUCIÓN DE CONTRATO – TERCERÍA DE DOMINIO DE VERAMOR DE MARMOL S.R.L. – EXPTE. N° 1503990/36”**, venidos del Juzgado de Primera Instancia y Cuadragésimo Novena Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, con motivo del recurso de apelación deducido por la parte actora en el juicio principal en contra del Auto Interlocutorio número un mil setenta y uno del diecisiete de noviembre de dos mil diez donde se dispuso: ***“ I. Hacer lugar a la tercería de mejor derecho deducida por la firma “Veramor de Mármol SRL” y en consecuencia ordenar la cancelación del embargo dispuesto en relación al inmueble inscripto a la matrícula n° 52121 Capital (11), por la suma de Pesos ciento treinta mil (\$ 130.000) , obrante al D° 8609 del 22/06/06, debiendo oficiarse a sus efectos. II. Imponer las costas a la firma “Repartidores de Kerosene de YPF de Córdoba. Hoy Muñoz Luis Alberto”, vencida. III. Diferir la regulación de honorarios de los señores letrados intervinientes para cuando haya base cierta para ello. Protocolícese, hágase saber y dese copia.”***-----

Concedida la apelación y elevada la causa a esta Sede, expresa agravios el apelante a fojas 320/330, los que son respondidos por la contraria a fojas 338/351, quedando la causa en estado de ser resuelta.-----

Y CONSIDERANDO:-----

1º) El apoderado de la parte actora en el principal se agravia de lo resuelto porque considera que es arbitrario por estar inmotivada o erróneamente motivada la solución legal. Expone que el hecho de que la comunicación de subasta no esté alcanzada expresamente por el párrafo tercero del art. 34 de la ley 5771, en modo alguno da lugar a aseverar que no tiene plazo de vigencia, ni de caducidad y que la supuesta ausencia de previsión normativa puede dar motivo a sostener que la comunicación de subasta dura mientras se sustancia el expediente judicial.-----

Agrega que para llegar a esa conclusión, el juez ha prescindido de normas jurídicas superiores como la ley 17.801 y resoluciones del Director General del Registro de la Propiedad. Dice que se ha violado lo regulado en los arts. 1º, 2º y 7º de la ley 17.801 y que el dogma de que “la comunicación de subasta no tiene plazo de vigencia o de caducidad” es rebatible.-----

Dice que las anotaciones previsionales caducan cuando se convierten en definitivas o transcurre el plazo de su vigencia (180 días, prorrogables). Destaca lo de la prorrogabilidad porque entiende que el legislador ha previsto que puede suceder que se pida la nulidad del remate (como el caso de autos), en cuyo caso solo basta con seguir prorrogando esa anotación, por todo el tiempo que sea necesario o dure el litigio, bastando una petición fundada del requirente. Por ello, considera que cae de su propio peso entonces aquello que obra en la sentencia apelada, de que la comunicación de subasta dura mientras se sustancie el litigio con tan solo un aviso como se ha resuelto en esta tercería. Considera que subsiste si ante cada vencimiento se va renovando días. Cita jurisprudencia que considera a su favor.-----

A continuación expresa que hay otra salida jurídica o, si se quiere, una previsión más puntual todavía, que es la prevista por la Resolución del Director del Registro General, numerada con el 14 del 28 de noviembre de 2005, vigente a la fecha en que se trabaron los

embargos cuyo levantamiento o cancelación persigue la tercerista que establece que la comunicación de subasta recibirá el tratamiento de una cautelar cuyo plazo de vigencia es de cinco años.-----

Por ello, considera que la comunicación de subasta caduca a los 180 días si no es prorrogada o a los cinco años, pero que no es de duración indefinida ni hasta que se termine el juicio como figura en la sentencia.-----

Agrega subsidiariamente que el plazo de cinco años también se deduce porque considera aplicable el inc. b del art. 2 de la ley 17.801 por remisión del art. 37 de la misma ley.-----

Dice que ninguna normativa del Registro señala que la inscripción provisoria conserva su validez mientras se sustancie el trámite judicial, por lo que considerar que no caduca la comunicación de subasta es desacertado, considerando que se ha violado la manda constitucional que exige que las resoluciones judiciales cuenten con una fundamentación lógica y legal.-----

Como **segundo agravio**, denuncia violación a las formas y solemnidades prescriptas para el dictado de la sentencia, porque considera que se ha practicado una maniobra defraudatoria al cederse los derechos de subasta que utilizó “Veramor de Mármol S.R.L.” para estar en este juicio, que tuvo como participantes a Salvador Calvo, Gustavo Alfredo Calvo, Sebastián Calvo y Oscar Silvero. Dice que de las testimoniales vertidas en los presentes se desprende que existió una maniobra o desbaratamiento de sus derechos con la cesión de la subasta, la cual quedó desenmascarada con dichas declaraciones y que acarrear la nulidad del pronunciamiento apelado.-----

Agrega que desde un primer enfoque, el A quo no ha reparado en la inidoneidad o inhabilidad del título usado para plantear o sustentar la tercería, lo cual fue alertado en los alegatos. Aclara que no se trata de una mera disconformidad sino que habiéndose descubierto el objetivo espurio, doloso y premeditado de burlar los intereses de la parte actora, no es válido el argumento expuesto por el sentenciante al señalar que “...*la tercería de mejor derecho resulta idónea para considerar la petición del levantamiento del embargo, solicitada por el tercerista en relación al inmueble inscripto a nombre de la garante de la demandada en el principal, con sustento en haberlo adquirido por cesión de derechos y acciones de quien en a su vez es cesionario del adquirente en la subasta; todo ello con anterioridad a la traba de la cautelar...*”.-----

Dice que el instrumento con que la actora pretende hacer valer su derecho es la culminación del ardid ideado y ejecutado por Salvador Calvo, con el apoyo de sus hijos, lo cual no es compatible con la esencia, función y estructura del juicio en que nos encontramos. Agrega que el tercerista no tiene la posesión del inmueble subastado y que no puede soslayarse que la fuerza o legitimidad de cualquier título en que se sostiene una demanda es otorgado por la ley, debe ajustarse a ella y debió el juez en autos investigar su conformación desde lo formal e invalidarlo por contrario a la ley, moral y buenas costumbres.-----

Expone que luce notorio que el A quo construyó su razonamiento con base en la propia caracterización de los títulos aptos para iniciar una tercería, con apoyo doctrinario y jurisprudencial, pero que la aparente legitimidad del instrumento de cesión se derrumba cuando se leen las declaraciones del abogado y testigos ya transcritas.-----

Avanzando en un **segundo enfoque** de este agravio, expone que existió falta de merituación de las declaraciones indicadas, que tienen aptitud para inhabilitar el título usado para demandar, lo cual provoca a su entender una violación a la sana crítica racional y congruencia del pronunciamiento. Dice que las mismas eran esenciales y decisivas para el fallo por lo que la omisión de tratamiento de las mismas torna nulo el fallo recurrido. Resalta

las mencionadas declaraciones como “claves para determinar la idoneidad del título, insinceridad del reclamo, dolo y mala fe del tercerista” que difiere rotundamente con la calificación tácita de cesión idónea que le otorga el sentenciante.-----

Sostiene que en el improbable caso de que dichas pruebas hayan sido analizadas y descartadas, no están brindadas las razones o el íter de su razonamiento para poder controlar su logicidad y legalidad.-----

Como **tercer enfoque**, afirma que existe violación a la fundamentación lógica porque no se ha realizado a su criterio, una ligazón racional de las pruebas rendidas y se ha omitido analizar prueba trascendente.-----

Como **cuarto enfoque**, insiste en que el comportamiento de la tercerista contraría la buena fe del art. 1198 del CC y que el accionar de Veramor de Marmol SRL no ha sido desinteresado ni casual, sino que la cesión fue el fruto de una maquinación tendiente a desposeer a San Nicolas de Bari SRL de su bien inmueble para no pagar la deuda que tiene con su instituyente infringiendo el art. 931 del CC.-----

Por ello, considera que se dan los elementos que configuran un fraude a la ley y que solo fue posible descubrirlo a partir del testimonio del Dr. Cima y de los empleados de Frutacor SA. Aduce que la desposesión fraudulenta afecta el principio de que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Sostiene que la cesión de derechos es inválida, lo cual radica en la ilicitud a la que dio lugar la conducta abusiva de las partes. Insiste en que existe una transgresión tanto formal como material del ordenamiento jurídico que es reprochable y que no puede ser avalado un título fundado en tal proceder para estar en juicio.-----

Trasladándose a la Ley de Sociedades Comerciales, afirma que ha quedado al descubierto en este actuado que los accionistas o socios y miembros de los órganos que tenían a su cargo la administración de las sociedades San Nicolas de Bari SRL, Frutacor SA y Veramor de Marmol SRL facilitaron o participaron de conductas temerarias o fraudulentas. Cita jurisprudencia e insiste en que el estado de insolvencia de San Nicolás de Bari SRL fue un objetivo deseado para defraudar los intereses de su parte, destacando que el resto de las sociedades involucradas y administradas por las mismas personas físicas no padecen de dicha situación patrimonial.-----

Conforme todo lo expuesto, solicita se haga lugar al recurso de apelación intentado, revocándose la resolución recurrida y rechazándose la tercería de mejor derecho articulado por San Nicolás de Bari S.R.L.-----

II).- Ingresando al análisis del recurso intentado, debemos precisar que el apelante centra su recurso en dos agravios, los cuales serán tratados independientemente y en el orden en que han sido expuestos a los fines de dar una acabada respuesta a cada uno de ellos, a saber: a) La existencia de plazo de caducidad de la comunicación de subasta (180 días o 5 años) y b) El fraude a la ley por parte del demandado al insolventarse mediante la cesión mencionada.-----

Ahora bien, de manera liminar debemos tener en cuenta algunas cuestiones que se han ido sucediendo en esta causa y que pueden sellar la suerte del presente recurso.-----

1) la subasta ordenada en la causa “Refinería de Maíz SAIC y F c/ San Nicolás de Bari SRL- EJECUCION HIPOTECARIA” (EXPTE N° 1099522/36) ha sido realizada en el plazo de duración de la anotación preventiva de subasta (o sea el 05.06.01) y debidamente comunicada

(06.06.01) y asentada con fecha 14.06.01 de conformidad a lo dispuesto en la Resolución del Registro 11/83, c/ I. provisoria por 180 días.-----

2) que el demandado ha planteado un incidente de nulidad de la subasta que fuera interpuesto con fecha 26.06.01 y rechazado en primera instancia, cuya confirmación por la alzada data del 11.03.03 (Auto N° 72 dictado por la Excma Cámara 2° CC).-----

3) que el tribunal que ha realizado la subasta ha omitido comunicar la interposición del incidente de nulidad al Registro y que en mérito a dicha omisión el ente registrador al vencimiento de los cinco años de la comunicación de subasta previsto por la resolución que resultaba aplicable en ese momento (Resolución N° 14/05) dió por concluido el bloqueo registral lo que terminó ocasionando que las cautelares que habían sido trabadas ad eventus de la continuidad de dicho bloqueo, adquirieran plena vigencia, lo que habría ocurrido con la cautelar ordenada por el Juzgado de 49 CC, el 22.06.06 (Diario de embargo N° 8604); habiendo sido trabados con posterioridad otros sendos embargos en la misma causa (ver último fichón de la matrícula 52121 (11) acompañada a fs. 914/918 de los autos “Repartidores de Kerosene de YPF de CBA SRL-Hoy Muñoz Luis Alberto c/ Frutacor SA-Ordinario (Expte N° 550522/36).-----

4) que el ejecutante que resultó comprador en la subasta solicita la aprobación de subasta con fecha 02.07.03 –reiterada con fecha 11.08.03-, habiendo cedido sus derechos primero a “Productos de Maíz SA” y ésta última a la empresa tercerista VERAMOR DE MARMOL SRL (Escritura N° 327 del 03.11.04), quien recién habría obtenido la aprobación de subasta con fecha 23.05.07 (ver copia auto de aprobación acompañado a fs. 13 de los presentes autos).

5) Que la tercerista no ha adquirido la posesión del inmueble, ya que ante su petición a fs. 510 en los autos donde se ha realizado la subasta con fecha 29.07.08, el Tribunal le decreta que el libramiento de dicho oficio se encuentra supeditado al previo pago de los impuestos que adeudaba el inmueble en cuestión; lo que habiendo tenido el expediente a la vista no se habría solucionado al día de la fecha.-----

A más de los puntos expuestos, debemos tener en cuenta que si bien el comprador se habría encontrado habilitado para solicitar la aprobación de la subasta con posterioridad a la resolución que ha dejado firme el rechazo del incidente de nulidad (que data del 2003), recién ha sido concretada dicha aprobación el 23.05.07; lo cual ha sido posterior a la fecha en que el Registro habría dado por concluido el bloqueo registral por vencimiento de la comunicación de subasta y habría anotado el embargo trabado por el Juzgado de 49 CC (23.06.06), cuyo levantamiento –y los demás embargos trabados en la misma causa -se pretende con esta tercería. Ello significa, que de permanecer la caducidad de la subasta ordenada por el Registro –insisto de conformidad a la normativa registral vigente a ese momento que es la número 14/2005- el comprador no sólo tiene el problema de que no ha adquirido la posesión, sino que al realizar su trámite de inscripción registral, deberá abonar y pedir el levantamiento de todos los embargos que han sido trabados con posterioridad a la caída del bloqueo señalado.-----

III.- Conforme a lo relatado, debemos recalcar -por más que la cuestión no haya sido motivo de agravio- y el juez de primer grado haya omitido su tratamiento, que a la fecha de la iniciación de la presente tercería la empresa peticionante no había adquirido formalmente la posesión en los términos del art. 598 del CPCC (situación que como hemos señalado permanece hasta el presente). Sobre el tema en nada incide que la propia tercerista haya manifestado que tiene la posesión desde el 2004 y que haya formalizado un contrato de alquiler en su carácter de locadora; ya que ello puede obedecer a una simple tenencia, que de ninguna manera puede implicar la existencia de una posesión; ya que no ha sido aún otorgada la tradición en la forma que marca la ley y por el juez de la subasta.-----

Con lo expuesto es dable señalar que a la fecha de toma de razón de la medida cautelar cuyo levantamiento se persigue con la presente tercería, alegando "un mejor derecho a la cosa", no se había operado la transmisión del derecho real de dominio respecto del inmueble subastado, ya que no se había cumplido con el modo; esto es no se había tomado posesión de aquel. Pues, debe tenerse presente que el dominio de un inmueble se adquiere por el título y modo, siendo la inscripción prevista por el art. 2505 del CC de naturaleza declarativa a los fines de la oposición de los derechos reales a terceros.-----

Sobre el punto se ha dicho que "En el caso del remate judicial de un inmueble, el título está constituido por: a) el acta de subasta en la que conste el precio obtenido y el nombre del comprador; b) la aprobación del acto y la adjudicación del bien a su nombre; y c) el pago del saldo del precio; en tanto que el modo está constituido por la entrega de la posesión al adquirente por orden del juez que dispuso la subasta, el que sustituye de esta forma al ejecutado en la tradición de la cosa. Recién cuando el comprador reúne el título y el modo se extingue el derecho de propiedad del ejecutado, conforme a lo establecido por el art. 2610 del CC. (C2ª CC Cba, en autos "Zucaría Lidia c/ Toranzo Humberto Guillermo y otro PVE-Alquileres-Cuerpo para la tramitación del recurso de apelación", Auto N° 10 del 10/02/05, Actualidad Jurídica N° 98). "Antes de la tradición de la cosa no se adquiere el derecho real. Es decir, que ésta cumple una doble función: constitutiva del derecho de dominio y de publicidad, para hacer conocer la trasmisión a los terceros. Es recién luego de cumplidos los dos requisitos: celebración del acto jurídico (título suficiente) y tradición, que el dominio pasa de la cabeza del tradens al accipiens, con todas las consecuencias que ello trae aparejado. (Mariani de Vidal María "Curso de Derechos Reales", Tomo 1, pag. 236, Bs.AS. 1976).-----

Es por ello que si bien no desconozco que este Tribunal de Alzada con anterior integración ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en autos "Linfar S.R.L. C/ Banco Rio De La Plata S.A. – Ordinario – Cobro De Pesos – Expte. 1074187/36" (Auto N° 27 del 22.03.10) –citado por el juez de primer grado- nos encontramos ante una distinta situación ya que en aquel caso el comprador tenía aprobación de la subasta (título) y entrega de la posesión (modo).-----

Es dable destacar jurisprudencia de alzada que se han expedido sobre el tema diciendo que: "La ausencia de posesión es dato fundamental, porque a falta de ella no llegó ni siquiera a nacer el derecho real que debía ser inscripto, lo que revela que el problema, o mejor dicho la desidia del adquirente, atañe más a los actos que debía realizar en sede judicial para obtener un documento inscribible que los trámites o procedimientos de la inscripción misma. **En esta situación no se puede decir que se esté frente a una situación ya consumada, a una transmisión ya sucedida de un derecho real, para cuya publicidad y oponibilidad a terceros pueda resultar suficiente el sólo asiento generado por la comunicación de la subasta. Asignarle esta eficacia aún en ausencia de posesión implicaría admitir que este asiento puede publicitar un estado jurídico inexistente y divorciado con la realidad de las cosas.**" (C3ª CCCba., "Domínguez Carlos Eusebio c/ Trucco, Eva Angélica y otro-Ejecutivo-Tercería de dominio de Fabiana Elisabeth B. Tamagnone y Rubén O navarro", Semanario Jurídico Tomo 102-2010- B, pag 593/594)(el destacado nos pertenece).-----

Esta doctrina resulta aplicable en la especie porque la cesionario de la adquirente en subasta del inmueble en cuestión obtuvo la aprobación de subasta con posterioridad al ingreso al Registro General del embargo ordenado por el ejecutante en los autos principales, sin que tampoco a esa fecha se hubiese puesto a la misma en posesión del bien; lo cual significa que

el trámite donde se realizó la subasta (aunque se hubiese inscripto la anotación preventiva) le resulta inoponible a la actora, atento a que al adquirente no se le otorgó la posesión, cuya virtualidad es publicitar el estado jurídico del inmueble. (CCiv.C y CA de San Francisco 25.04.11, Auto 68, "Ramallo Perlina Etelvina c/ Metalúrgica Pecayna SA- Demanda ejecutiva", Revista Zeus Córdoba N° 451/11 pag.249).-----

Y por último lo que ha dicho la doctrina sobre el tema *“A partir de la comunicación es menester informarse sobre el trámite que ha seguido al remate, que puede concluir con su rechazo, caso en el cual no habrá adquirente y deberá cancelarse la anotación provisional, o con su “aprobación”, que, unida a la entrega de la posesión, convierte al adquirente en “propietario civilísimo”* (Moisset de Espanés, Luis, *“¿Tiene plazo de caducidad la inscripción que da noticia de la realización de una subasta?”* Lexis Nexis Córdoba 2007-3-217)); lo que de manera alguna debemos dar por supuesto en la presente causa.-----

IV.- Ahora bien, dejando de lado el tema de la falta de toma de posesión y en atención a que el agravio del apelante gira en torno a la caducidad de la comunicación de subasta, pasaremos a abordar dicho tema.-----

En primer lugar debemos subrayar que la comunicación de subasta que se encuentra discutida, fue asentada el 14.06.01 cuando se encontraba vigente la Resolución del Registro N° 11/83 la cual establecía la caducidad de la anotación preventiva de subasta una vez transcurrido el plazo de validez del mismo, con más el término consagrado en el art. 5 de la ley 17801. Así surgía de los considerandos de la resolución: “...4) Que el artículo 5° de la Ley 17801 determina que las escrituras públicas deben presentarse al Registro dentro del plazo de cuarenta y cinco días, contados desde su otorgamiento, para que su registración sea considerada a la fecha de su instrumentación. Que si bien esta disposición se refiere al documento notarial, una interpretación orgánica de dicha ley, nos lleva a la conclusión de que los demás documentos previstos en el Artículo 3° de la ley 17801 y celebrados con certificados registrales con reserva de prioridad, deben ser presentados a los cuarenta y cinco días de su otorgamiento para ser registrados a la fecha de su instrumentación...”.-----

En conclusión, de acuerdo a dicha normativa, era menester realizar una inscripción provisional del documento de que se trata, conforme a lo prescripto por el artículo 9 inciso b) de la Ley 17801, dentro del cual debía completarse el trámite procesal judicial necesario para inscribir definitivamente el inmueble adquirido en remate a nombre del comprador en subasta –y es lo que ha ocurrido en la comunicación obrante en la matrícula 52121 (11)-.-----

Con posterioridad a dicha normativa fue dictada la Resolución General N° 26/2002, -en la cual no ahondaremos por no tener consecuencias en la presente causa - y la Resolución General N° 14/2005, la que se encontraba vigente al momento en que el Registro declara la caducidad automática de la comunicación de subasta en la matrícula referenciada. Asimismo consideramos inapropiado resolver la cuestión suscitado teniendo como marco normativo resoluciones dictadas con posterioridad a dicha caducidad.-----

En la Resolución N° 14/05, en realidad lo que resuelve el Registro General es asignarle al instituto jurídico-registral de la comunicación de subasta el tratamiento de una medida o providencia cautelar cuyo plazo de vigencia era de cinco años (de conformidad al art. 37 de la ley 17801). Este criterio ha sido mantenido por la Resolución General Número Uno de fecha 22.09.06 y por la Resolución General Número Uno de fecha 01.08.07; siendo posteriormente modificado por la Resolución Número 1 del 25.06.08 y subsiguientes donde se consagra que la comunicación de subasta no se encuentra sujeto a plazo de caducidad.-----

Teniendo en cuenta las normativas registrales relacionadas y lo dispuesto por el art. 3 del Código Civil, considero que el tercerista yerra en su presentación cuando solicita la inconstitucionalidad de la Resolución N° 11/83, ya que si bien la comunicación de subasta se

realiza bajo la vigencia de dicha normativa –realizando una anotación provisoria por 180 días-, la caducidad de la misma ha sido ordenada aplicando el plazo de cinco años dispuesta por la Resolución N° 14/2005.-----

En esta línea conceptual, y si bien no desconocemos los planteos realizados por los doctrinarios especialistas en derecho registral sobre la falta de competencia o atribución de los funcionarios del registro para establecer plazos de caducidad en razón de una interpretación restrictiva de los mismos –y que ha sido uno de los puntos en que el juez del primer grado ha asentado su resolución-; debemos precisar que en el caso puntual de la Resolución N° 14/2005 no es que se establezca directamente un plazo de caducidad, sino que la resolución enmarca a la comunicación de subasta como “medida o providencia cautelar”, y es en función de dicha naturaleza que su plazo de vigencia se limita a los cinco años desde su traba efectiva y la que en definitiva ha motivado la caída de dicha medida y la entrada de las cautelares que se encontraban pendientes en razón del bloqueo registral ocasionado por la comunicación de subasta.-----

Esta cuestión no ha sido controvertida ni impugnada por el tercerista, quien se ha limitado a plantear la inconstitucionalidad de la resolución N° 11/83; la que por los motivos expuestos no merece el mayor análisis.-----

Llegado a este punto, cabe reflexionar sobre la naturaleza de la comunicación de subasta; lo que igualmente se encuentra controvertida en la doctrina y jurisprudencia local. No hay duda que dicha comunicación cumple con una finalidad preventiva o precautoria que consiste en anotar a los terceros acerca de la realización de una subasta a los fines de su oponibilidad; y en nada incide que se trate de un acto jurídico registral de naturaleza sustancial, porque tenemos distintas medidas cautelares que gozan de dicha naturaleza y que se encuentran prevista en distintas normas sustanciales (vgr ruidos molestos, exclusión del hogar, etc).-----

Por otra parte cabe precisar, que a diferencia de lo que sucede en el ámbito notarial en que por imperio del denominado “principio de unidad de acto” (que todo sucede en el mismo momento); en materia judicial y especialmente en la subasta, el acto del remate implica o marca el momento en el que comienza a nacer el título de adquisición, el que se va gestando en diferentes instancias (que los procesalistas llaman actos previos y posteriores a la subasta) y el que se encuentra sujeto a varias vicisitudes procesales. Ello es así, ya que dictado el auto de aprobación de subasta, sino ha mediado eximición de consignar o no se han pagado las acreencias de mejor derecho (como es el caso de autos donde se está solicitando el pago de los impuestos para librar el oficio de toma de posesión); y el comprador no abone dicho saldo, nos encontraremos frente a la figura del comprador remiso previsto en el art. 585 del CPCC, que concluye con la realización de una nueva subasta.-----

Es por ello que consideramos que no resulta desacertada la naturaleza de “providencia cautelar” entendida como medida asegurativa propiamente dicha; ya que en definitiva se trata de una “preanotación” a los fines de evitar en forma inmediata el ingreso de medidas cautelares en el tiempo que media entre el acto de remate y la inscripción definitiva del bien inmueble en cuestión y en forma mediata y cuando no corresponda, evitar “la doble subasta”. Basta citar la doctrina sustentado por un fallo dictado a nivel nacional que expresa: “...Para que la venta efectuada en subasta judicial pueda ser opuesta a terceros, la orden de subasta debe comunicarse al Registro de Propiedad a fin de que éste efectúe la “preanotación” pertinente. De no tomarse ese recaudo la transmisión no podrá oponerse al embargante

posterior, respecto del cual rige plenamente el sistema de publicidad ideado por la Ley 17801. La inscripción que el comprador en remate efectúe con posterioridad a la anotación del embargo, no eximirá al titular de las consecuencias de la medida adoptada...” (Cámara Civil y comercial de Mar del Plata, Sala 2º, 04.02.03, “Longo, Walter M. s/ Tercería de Dominio en autos Collia v. Fucci s/ Ejecución de alquileres; citado por Fuster Gabriel Aníbal en su trabajo “La pretendida caducidad de la comunicación de subasta”). Es en definitiva lo que expresa nuestro artículo 13 de la Ley 5771 cuando establece que durante la vigencia de la inscripción provisional, podrán realizarse otras con respecto al inmueble o derecho real de que se trate, advirtiéndose en todos los casos la calidad de la inscripción.-----

Por su parte AHUMADA, si bien no le reconoce naturaleza cautelar, considera que como la comunicación de subasta produce una inscripción provisional en los términos del inciso b) del art. 9 de la LNR, le corresponde aplicar a ella los mismos plazos de caducidad; en particular se le debe aplicar la caducidad automática prevista en la R G N° 25/99, que es la que establece la vigencia de las mismas por un plazo de cinco años. (ver Daniel E. Ahumada en “Ley Registral Inmobiliaria 5771 y disposiciones técnico-registrales” (comentada, concordada y anotada) en Alveroni Ediciones, Córdoba 2002, página 328). Ello es así, ya que el artículo 9 de la Ley 17801 citado en su último párrafo establece que “Las inscripciones y anotaciones provisionales caducan de pleno derecho cuando se convierten en definitivas o transcurre el plazo de su vigencia”; ergo si consideramos a esta comunicación como una anotación provisional –llamada preventiva por el art. 34 tercer párrafo de la ley 5771- es desacertado pensar que pueden tener una duración indefinida para lograr su inscripción definitiva.-----

Los mismos doctrinarios especialistas en esta materia, reconocen que nos encontramos con una laguna normativa registral, ya que tanto la ley nacional como provincial no establecen reglas claras con relación a la mecánica registral de la reserva de prioridad cuando se trata de documentos judiciales (FUSTER, Gabriel Anibal “Aspectos Registrales de la subasta judicial”); por lo tanto la solución es partir de la naturaleza jurídica establecida por la normativa registral –anotación preventiva- para medir sus consecuencias relacionadas con la misma (vgr su caducidad).-----

En este mismo sentido si bien sostiene que el art. 5 de la ley 17801 resulta aplicable tanto al documento notarial como judicial, pero que no sucede lo mismo con el artículo 9 inciso b) de la misma ley por entender que ésta última es solo aplicable a los documentos notariales, toda vez que contempla un supuesto patológico que “el documento notarial defectuoso”; en el caso de la comunicación de subasta consideramos que dicha normativa resulta aplicable, ya que por su carácter de acto progresivo o “título en gestación”, dicha anotación si bien no es defectuosa en su sentido estricto, resulta registralmente defectuosa por “incompleta”, ya que está supeditada al ingreso del cuadernillo de inscripción cuando se hayan cumplimentado todos los pasos previstos como actos posteriores en nuestra ley ritual. Si el comprador interesado no completa este trámite en un plazo estipulado, consideramos que esa omisión puede volverse “patológica”, sobre todo cuando la falta de inscripción puede obedecer a una maniobra fraudulenta para sacar el bien que permanece a nombre del ejecutado de la posibilidad de ser perseguido por otros acreedores (y en muchos casos es el mismo ejecutado el que permanece en él).-----

Asimismo no consideramos que la solución sea considerar que el plazo de este vencimiento sea el de la prescripción de la actio iudicati de la resolución que aprueba la subasta, ya que el mismo no resuelve todos los casos que puedan plantearse. Ya que para que hablemos del auto de aprobación de subasta como resolución firme y ejecutoriada debemos referirnos a resolución en condiciones de ser ejecutada –o sea en condiciones de proceder a la

inscripción del inmueble a nombre del comprador- para lo cual debe haber mediado el pago del precio y la puesta en posesión; excediendo dicho concepto de firmeza, la simple notificación de la misma y la inexistencia o confirmación de los recursos.-----

De todas maneras, y aún para el caso de que no la asumamos a esta comunicación como una medida “provisional” en los términos del art. 9 inciso b) de la Ley 17801, nuestra ley le ha definido una naturaleza “preventiva” y como tal no puede tener de ninguna manera una duración indefinida; porque ello perjudica nada más ni nada menos que la seguridad jurídica. Dice sobre el tema Carmelo Díaz González “...Se dice que una anotación caduca cuando pierde toda su validez y eficacia a consecuencia de su mismo contenido o por declaración de la ley, sin necesidad de una manifestación de la voluntad de los interesados ni una declaración judicial o administrativa. En las notaciones preventivas son más frecuentes las causas de caducidad que en las inscripciones, puesto que son asientos provisionales a los que la ley asigna un plazo de vigencia determinado, cuyo transcurso provoca de derecho la caducidad de la anotación...” (autor citado en “Iniciación a los estudios de Derecho Hipotecario II, pag. 315, Madrid 1967).-----

V) Deslindado ese tema, nos resta dilucidar si el plazo se encontraba vencido habiendo mediado un incidente de nulidad del juicio por vicios de la citación inicial y por ende de la subasta realizada. Sobre el tema establece el tercer párrafo del art. 34 (segunda parte) de la ley 5771 que si el acto de subasta fuere observado, el tribunal deberá comunicar al Registro en el plazo indicado tal circunstancia, prorrogándose la inscripción preventiva hasta la notificación al Registro de la resolución definitiva que recaiga en la incidencia; lo que no ha sucedido en el caso de autos.-----

Si bien es cierto que ha existido una omisión de comunicación del planteo de dicho incidente por parte del tribunal, también cabe recalcar que ninguna medida ha tomado el comprador-cesionario de la subasta a partir de la fecha de la cesión (03.11.2004) con relación a dicha omisión y los perjuicios que le podrían ocasionar; más aún si tenemos en cuenta la legitimación que le brinda en esos supuesto el art. 6 de la ley 17801. Entendamos esto, a VERAMOR DE MARMOL SRL se le han cedido los derechos y acciones que tenía Productos de Maíz SA – a su vez cedidos por Refinerías de Maíz SA- con relación a un bien adquirido en subasta inscripto en la matrícula 52121 a nombre de San Nicolás de Bari SRL; por lo que debió haber tomado conocimiento del estado que se encontraba dicha subasta y la situación registral de dicho inmueble y en todo caso petitionar al Tribunal que pusiera de manifiesto al Registro que durante el plazo que se estuvo tramitando el incidente de nulidad debían suspenderse los plazos de caducidad. Por lo tanto, sino había mediado comunicación de la nulidad impetrada, no podemos hablar de una prórroga automática de los cinco años que se encontraban corriendo en función de la Resolución 14/2005 y la decisión adoptada por el Registro de inscribir el embargo librado por el Juzgado de 49° Nominación con fecha 22.06.06 –o sea a los cinco años de la anotación preventiva o provisional- luce acertado.-----

Ahora bien, como la buena fe es un elemento insoslayable a la hora de analizar la subasta y su comunicación; en atención a que este tipo de caducidad automática puede ocasionar que el titular registral pretenda disponer nuevamente de su inmueble (ya que la ley procesal y registral cordobesa no obliga al juez a tener el título para poder subastar) o el acreedor embargante a quien se le ha publicitado la existencia del asiento registral pretenda continuar con la ejecución, consideramos ajustado a derecho que la salida debe ser la

tramitación en el expediente judicial donde se ha realizado la subasta primigenia de la cancelación de dicho asiento de comunicación de subasta.-----

También debe tenerse presente que el plazo de cinco años es un término razonable en el cual quien ha comprado en subasta debe actuar diligentemente para lograr su inscripción definitiva o, en su caso, solicitar una nueva anotación de la misma. En este sentido, si en dicho plazo no ha cumplimentado ninguna de las actitudes señaladas, no existen dudas de que obra con negligencia o pereza respecto del bien en cuestión, situación que no puede ser amparada y protegida por la ley ni por los Tribunales.-----

Por otra parte nos adherimos a las soluciones que pregona el Dr. Fuster (en “Aspectos registrales de la subasta judicial”) en el sentido de que debería corregirse la falta de previsión normativa a nivel ritual acerca de quién es el obligado a concluir con la inscripción definitiva del bien raíz subastado, y establecer una sanción frente a su omisión.-----

En este punto considero a nivel personal que la solución sancionatoria sería - aún cuando la comunicación de subasta le diéramos un plazo de sine die (con prescripción de 10 años) para que el comprador la anote a su nombre –siempre que medie buena fe del comprador en su demora- el transcurso de los cinco años le haga caer el bloqueo registral, lo que va a terminar implicando que al momento de inscribir deberá tomar a cargo los embargos que han ingresado frente a la caída del bloqueo o en su caso, concurrir a cada uno de los tribunales y solicitar el levantamiento de los mismos.-----

Por todo lo expuesto, me eximo de entrar a considerar el segundo agravio planteado por la recurrente; dejando a salvo que la cuestión no ha sido estrictamente ventilada en la primera instancia y que por otra parte se están tramitando ante el mismo Tribunal de la tercería, sendas demandas ordinarias sobre la cuestión que versa dicho agravio .-----

La solución.-----

Por todo lo expuesto, debe declararse la caducidad de la comunicación de subasta, y en atención a dicha caducidad y la falta de posesión del peticionante rechazarse la tercería impetrada por no revestir un mejor derecho a la cosa.-----

De lo hasta aquí dicho, se desprende que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por parte de la actora en el principal, revocar la resolución recurrida en todo cuanto dispone y rechazar la tercería de dominio –de mejor derecho a la cosa- interpuesta por Veramor de Marmol SRL.-----

Con respecto a las costas generadas en la presente causa, cabe tener presente que, así como se ha citado doctrina y jurisprudencia a favor de la postura que aquí se propicia, no se desconoce que también existen fallos y posturas en sentido opuesto. Por ello, atento a la existencia de jurisprudencia y doctrina contradictoria y vacilante en la materia que nos ocupa, corresponde imponer las costas en ambas instancias por el orden causado (arg. Art. 130 *in fine* del CPCC).-----

Por todo ello; **SE RESUELVE:** 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por parte de la actora en el principal, revocar la resolución recurrida en todo cuanto dispone y rechazar la tercería de dominio –mejor derecho a la cosa- interpuesta por Veramor de Marmol SRL. 2) Imponer las costas de ambas instancias por el orden causado.- Protocolícese, hágase saber y bajen.-

CLAUDIA E. ZALAZAR
VOCAL

RAFAEL ARANDA
VOCAL

JOAQUIN F. FERRER
VOCAL